

1500806-63.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... possuir uma condenação por tráfico de drogas e por receptação. Revelou que outras buscas foram realizadas no local pela polícia militar, porém nada de ilícito foi localizado.

Declarou que sua esposa já foi processada pelo crime de tráfico de drogas, acrescentando que Tatiane não possuía emprego formal na época dos fatos, mas trabalhava como diarista. Indagado, asseverou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1500806-63.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO PAULO DA SILVA GONÇALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

V I S T O S.

JOÃO PAULO DA SILVA GONÇALVES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 329, do Código Penal, ambos c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 02 de junho de 2021, por volta das 10h45, na Rua Anhanguera, no. 3-A - Centro, nesta cidade e Comarca de Birigui, em ocasião de calamidade pública, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega e consumo de terceiro, 21,23 gramas (massa bruta) de benzoilmetilecgonina, droga vulgarmente conhecida como cocaína, transformada em crack.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, JOÃO PAULO DA SILVA GONÇALVES opôs-se a execução de ato legal, mediante violência, a funcionário público competente para executá-lo.

A denúncia foi recebida às fls. 112/113. O réu foi citado, apresentando defesa prévia às fls. 131/134. A denúncia foi aditada às fls. 156/157, sendo o aditamento

devidamente recebido também às fls. 156/157.

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas em comum, interrogando-se posteriormente o réu. (fls. 156/157). Em seus memoriais finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência da acusação e, por conseguinte, a condenação do réu nos termos da denúncia ofertada. Requereu, ainda, a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, a fixação de regime fechado para início de cumprimento da pena, a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis processual. (fls. 161/166).

A defesa, a seu turno, se manifestou em memoriais finais às fls. 169/184, requerendo a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal ou em razão da aplicação do princípio do in dubio pro reo. Em caso de entendimento diverso, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para o crime previsto no artigo 28, da Lei de Drogas. E por fim, caso haja condenação, requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação de regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena, bem como a concessão do direito de recorrer em liberdade. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é parcialmente procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução processual penal, a materialidade quanto ao delito de tráfico de drogas restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/15, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 auto de constatação prévia de entorpecentes de fls. 51/52, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 91/93, bem como pelos demais depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada. Vejamos.

Destaca-se inicialmente que o réu negou a prática do tráfico. Interrogado em juízo, João Paulo alegou que a droga localizada em seu poder se destinava ao consumo pessoal. Segundo o depoente, os policiais militares de imediato ingressaram no imóvel e como havia usado droga, saiu correndo assustado, porém, negou que tenha resistido à abordagem.

Ao ser questionado, o depoente declarou ter adquirido a droga pelo valor de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), sendo que o pagamento foi efetuado com dinheiro proveniente de "bicos". Acrescentou, ainda, que o dinheiro apreendido era destinado ao pagamento de uma conta.

O depoente confirmou aos policiais que a droga lhe pertencia, mas esclareceu que era para consumo pessoal. Indagado, o réu acredita que existem denúncias acerca da traficância em sua residência porque é usuário, informando possuir uma condenação por tráfico de drogas e por receptação. Revelou que outras buscas foram realizadas no local pela polícia militar, porém nada de ilícito foi localizado.

Declarou que sua esposa já foi processada pelo crime de tráfico de drogas, acrescentando que Tatiane não possuía emprego formal na época dos fatos, mas trabalhava como diarista. Indagado, asseverou ter sido condenado pelo crime de posse de drogas, bem como condenado pelo crime de tráfico no ano de 2012.

Por fim, relatou que as lesões constatadas no laudo pericial de fl. 69 foram decorrentes de uma queda que sofreu no momento da fuga.

Por sua vez, o policial civil Fausto Haruo Ashihara declarou ter recebido diversas denúncias de que uma pessoa de epíteto "Tatinha" estava realizando o tráfico de drogas em sua residência, razão pela qual foi expedido um mandado de busca e apreensão. Ao dar cumprimento ao mandado de busca, chamou pela moradora Tatiane, momento em que João Paulo, que estava no interior da residência, correu para os fundos e tentou arremessar um involucro plástico no telhado.

Segundo o depoente, como não conseguiu empreender fuga, João Paulo rasgou o involucro plástico e investiu contra os policiais, sendo contido. Declarou ter recolhido 22 porções de droga, além da quantia de R\$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais), em notas diversas. Indagado, João Paulo admitiu que o entorpecente lhe pertencia, admitindo, ainda, que a droga se destinava à comercialização.

De acordo com a testemunha, o réu declarou que Tatiane, sua esposa, nada tinha a ver com a traficância, afirmando ainda, que o dinheiro localizado em seu poder era proveniente da venda das drogas. Negou que o réu tenha declarado que a droga era para consumo pessoal, acrescentando que o local já era conhecido por ser ponto de venda de drogas, já tendo sido, inclusive, objeto de diligências anteriores, as quais também denunciavam que João Paulo comercializava drogas. Revelou que o réu é conhecido nos meios policiais, sendo reincidente pelo tráfico de drogas.

Indagada, a testemunha negou que tenha localizado outros petrechos normalmente utilizados no tráfico além da droga, dinheiro trocado em notas diversas e um aparelho celular. Declarou ter realizado diligências na residência em outra oportunidade, não se recordando acerca da localização de entorpecentes no local.

Ao ser questionado, asseverou que o nome do réu não constou no mandado de busca e apreensão porque a polícia civil não possuía qualificação do amásio de Tatiane, desconhecendo se tratar da pessoa de João Paulo, a qual já era conhecida nos meios policiais.

A testemunha declarou que a polícia civil possuía informação de que a pessoa de "Tatinha" e seu amásio estavam realizando o tráfico de drogas, negando que tenha a comprovação de que o dinheiro apreendido seja proveniente do tráfico. Relatou novamente que João Paulo confirmou que as drogas localizadas eram para a comercialização.

Ao ser questionado, o policial declarou que o primeiro ato policial foi conter o acusado, uma vez que João Paulo tentou se evadir e dispensar as porções de drogas, além de ter investido contra a equipe policial. Relatou ainda, ter exibido o mandado judicial, além de ter comunicado a João Paulo acerca dos motivos das buscas, asseverando ter indagado o réu sobre a traficância, o qual confessou a prática do crime aos policiais. Por fim, declarou ter dito ao réu sobre o seu direito de permanecer em silêncio. A testemunha esclareceu que João Paulo alterou sua versão perante a autoridade policial, relatando que a droga localizada era para consumo pessoal.

No mesmo sentido foi a declaração do policial civil Marcio Gomes Agatielo acrescentando que João Paulo confessou a traficância, alegando que estava desempregado na época dos fatos. Segundo o depoente, o réu isentou a companheira Tatiane da comercialização de drogas, negando conhecer João Paulo nos meios policiais.

Indagado, o policial não se recorda se a denúncia recaía também sobre João Paulo, e que não participou de diligências anteriores no local. Acrescentou que o imóvel era alvo de frequentes denúncias acerca do tráfico, afirmando que a polícia militar já realizou diligências anteriores na residência.

A testemunha declarou ter cientificado o réu sobre os direitos constitucionais de permanecer em silêncio, asseverando que João Paulo confessou a traficância no local dos fatos. Informou que a droga localizada, o dinheiro apreendido em notas diversas, bem como os antecedentes do réu, indicam o comércio espúrio, negando que outro petrecho tenha sido localizado.

Pois bem. Conforme sobressai do conjunto probatório, a negativa do réu restou isolada nos autos.

Com efeito, inicialmente destacam-se os depoimentos uníssonos dos policiais, que fizeram suas declarações com convicção narrando os fatos de forma veemente. Referidos depoimentos, cabe ressaltar, têm valor probatório idêntico àquele prestado por outras pessoas, notadamente se em sintonia com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos.

É ilustrativo o escólio jurisprudencial adiante colacionado, do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“PROVA – Testemunha – Policial – Revestindo-se de inquestionável eficácia o depoimento de servidores policiais, não se pode desqualificá-lo por emanar de agente estatal incumbido da repressão penal, circunstância que não afeta positiva ou negativamente o valor de sua palavra – Recurso não provido.” (Apelação Criminal n. 990.08.040006-1 – Limeira – 16ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Newton Neves – 10.02.09 – V.U. – Voto n. 6224).

Sendo ainda entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal: “É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.” (...) STJ - HC 76.557-RJ 2ª T., rel Carlos Velloso, 04.08.1998.

No caso vertente, o réu negou a prática do crime em juízo, mas confessou a propriedade das drogas para consumo próprio. No entanto, a versão exculpatória restou isolada do conjunto probatório.

Isso porque, os policiais civis foram uníssonos em relatar que o réu foi surpreendido no interior do imóvel – local objeto de diversas denúncias de venda de drogas – sendo que notar ao presença da equipe policial tentou empreender fuga pelos fundos da residência, além de tentar dispensar as porções de entorpecentes, certamente com intuito de não ser responsabilizado.

Anoto por oportuno, que a testemunha Fausto Haruo Ashihara foi categórico ao afirmar que a residência era alvo de inúmeras denúncias, asseverando que o mandado de busca e apreensão judicial foi expedido unicamente em nome de Tatiane porque a polícia civil não possuía conhecimento de que João Paulo – pessoa conhecida nos meios policiais – também residia no local.

Vale ressaltar que, para fins de reconhecimento do delito, desnecessária a comprovação da venda efetiva do entorpecente. A quantidade e a forma de acondicionamento são suficientes para a conclusão de existência de crime de tráfico de entorpecente. É o caso dos autos.

Nesse raciocínio, para a configuração do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, basta o ato de “Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, não se exigindo o ato de mercancia.

Outrossim, não se pode ignorar que o próprio confessou informalmente aos policiais

civis que estava desempregado e por este motivo decidiu comercializar entorpecentes. Ademais, o réu admitiu que a quantia em dinheiro apreendida era fruto do comércio espúrio de drogas.

Ainda, importante mencionar as circunstâncias da apreensão, fundamentais a atestar a finalidade mercantil dos entorpecentes. No caso concreto, a qualidade das drogas apreendidas (cocaína em forma de "crack"), a quantidade e a forma de acondicionamento (22 porções), e a presença de dinheiro em notas trocadas (R\$156,15) confirmam as inúmeras denúncias recebidas pelos policiais civis e evidenciam o destino mercantil das substâncias entorpecentes.

Segundo o magistério de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, na obra "Legislação Penal Especial", ed. Atlas, 2ª edição, p.122: "Ressalte-se, porém, que a comprovação elementar do tipo previsto no art. 16 - uso próprio - nem sempre é de fácil constatação, prevendo a própria lei, em seu art. 37, alguns critérios legais. Assim, para efeito de caracterização das condutas criminosas previstas na Lei nº 6.368/76, deverão ser analisados a natureza e quantidade da substância apreendida, o local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Deve, igualmente, ser levada em conta para efeito de tipificação do delito a forma de acondicionamento da substância entorpecente.".

Dessa modo, incabível a desclassificação da imputação para o delito de porte de drogas para consumo próprio, pois as circunstâncias demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes, conforme acima mencionado. De mais a mais, ainda que se entendesse comprovado que o réu é usuário de drogas, certo é que tal circunstância não afasta a prática do tráfico. Em outras palavras, o usuário pode ser traficante.

Por outro lado, o conjunto probatório não demonstrou a prática do crime de resistência.

Conforme é sabido, para a configuração do delito de resistência, é necessário que o sujeito ativo oponha-se ao ato legal, mediante violência ou ameaça. No elemento "violência", é necessária uma conduta atuante e positiva, ou seja, o crime só se perfaz com a chamada *vis corporalis* - força empregada contra a pessoa.

NELSON HUNGRIA leciona que "A oposição deve ter, na espécie, um caráter militante. A simples desobediência ou resistência passiva (*vis civilis*) poderá constituir outra figura criminal (art. 330), sujeita a penalidade sensivelmente inferior. Se não há emprego de violência (*vis physica*, *vis corporalis*) ou de ameaça (*vis compulsiva*), capaz de incutir medo a um homem de tipo normal, limitando-se o indivíduo à inação, à atitude gôndica, à fuga ou tentativa de fuga, à oposição branca, à manifestação oral de um propósito de recalcitrância, à simples imprecação de males (pragas), não se integra a resistência"(Comentários ao Código Penal. Volume IX. 2ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 411).

No caso dos autos, a prova oral revela que o acusado alterou-se ao não concordar com a abordagem policial. Contudo, não há qualquer descrição acerca da suposta atitude violenta do réu contra os policiais civis. Em outras palavras, as vítimas não especificaram qual teria sido a conduta, limitando-se a dizerem que João Paulo "tentou vir pra cima dos policiais".

Ademais, não há nada nos autos que comprove luta corporal entre os agentes e o réu, tampouco existe qualquer laudo pericial nesse sentido. Assim, não restou cabalmente demonstrado que o denunciado se opôs à execução do ato legal mediante violência ou grave ameaça, sendo de rigor sua absolvição.

A jurisprudência pátria é no sentido de que: "Resistência. Delito não configurado. Acusado que apenas protestou contra sua prisão, que considerava injustificada.

Absolvição decretada. Apelação provida. Inteligência do art. 329 do CP. (...) Não configura o delito de resistência o fato de o acusado, ao ser preso, sob o efeito ou não de estupefacientes, esbravejar e protestar contra os policiais que o detinham". (RT 543/322-3).

TACRSP: "Resistência. Delito não caracterizado. Mera indisciplina do acusado, ao ser preso, rebelando-se contra seus detentores. Absolvição mantida (...)." (RT 423/422).

"O elemento violência exigido pelo crime de resistência se refere tão-somente à "vis compulsiva", ou seja, a força empregada contra a pessoa" (JTACRIM20/59). Assim, quanto ao delito de resistência, em razão da fragilidade do conjunto probatório, outro caminho não resta que não a absolvição.

Passo, pois à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, e 42, da Lei de Drogas, verifica-se que o réu ostenta maus antecedentes (Cf. Fls. 57/58 – Proc. nº 0009972-11.2010.8.26.0077 e Proc. nº 0011509-71.2012.8.26.0077, nada havendo nos autos acerca da mencionada reabilitação criminal), o que recomenda a exasperação da pena base. Dito isso, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria da pena, reapreciando entendimento anterior adotado por esse juízo, incabível a agravante prevista no art. 61, inc. "j", do Código Penal, eis que não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretada em virtude da pandemia do COVID-19.

Nesse mesmo entendimento: "APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes com a recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminosa e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1512067-20.2020.8.26.0228, Rel, Des. Andrade Sampaio, v.u., j. 12.02.2021).

Assim sendo, mantenho a pena inalterada.

Na terceira fase, incabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4ª, da Lei 11.343/06, porquanto o réu ostenta maus antecedentes e há indícios de que se dedique a atividades criminosas, notadamente porque o local dos fatos era alvo antigo de inúmeras denúncias. Assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razão da natureza hedionda do delito de tráfico de entorpecente e dos maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. Por identidade de razões, incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis processual, por incompatibilidade lógica.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido por meio da presente ação penal para:

a) CONDENAR JOÃO PAULO DA SILVA GONÇALVES, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de provas de que o acusado possui boas condições financeiras.

b) ABSOLVER JOÃO PAULO DA SILVA GONÇALVES qualificado nos autos, da imputação do artigo 329, do Código Penal, ambos c.c artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado e o réu poderá recorrer em liberdade, eis que respondeu ao processo solto (Cf. fls. 86/87). Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Por fim, anoto que eventual detração da pena deverá ser deduzido perante o juízo da execução penal.

Transitada em julgado a presente decisão, comunique-se a Justiça Eleitoral para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

Determino a incineração da droga, caso essa providência não tenha sido adotada. (Fls. 16/17 e 51/52).

Inexistindo demonstração da procedência lícita do dinheiro e aparelho celular apreendido (fls. 16/17 e 89), conclui-se que se tratam de instrumentos e produtos do tráfico de entorpecentes, razão pela qual decreto o perdimento em favor da União, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento, instruindo-se o ofício com as cópias mencionadas no parágrafo anterior.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, o disposto no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Birigui, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA